

第42問

甲（46歳、男）は、タクシー運転手として勤務していたA社を退職する際に交付された退職金の金額が思っていたよりも少なかったことに腹を立てた上、A社の営業部長であるB（52歳、男）が、毎日、前日分の売上金を営業所から本社に届けることを知っていたため、Bを脅して売上金を自分のものにすることを企てた。

そこで、甲は、あらかじめ刃体の長さ16.5センチメートルの出刃包丁を用意し、前日分の売上金を本社に届けるため営業所を出発しようとしているBに、「ちょっとそこまで送ってくれ。」と言ってBが乗っている自動車の助手席に乗り込んだ。

甲は、Bが発車させる前に、出刃包丁を取り出し、右手に持って上着の下に隠した上、Bが売上金を入れて運転席の左横においていたビニール袋を左手でつかみ、これを奪い取ろうとしたが、Bに奪い返されたため、右手に持った出刃包丁をBの左脇腹付近に突き付け、「金よこせ。」などと言いながら、左手でビニール袋を引っ張った。しかし、Bは、元同僚である甲が、まさか本当に刺してくるとは思わなかったこともあり、これにひるむことなく、ビニール袋を離そうとしなかったため、引っ張り合いになり、ビニール袋が破けてしまい、そのはずみで、売上金の一部が車外に落ちてしまった。Bが、甲に対して、「拾って来い。」と厳しい口調で命じたため、甲は、即座に、出刃包丁を上着の内ポケットにしまい、このビニール袋を助手席において下車し、車外に落ちた売上金を拾った。甲は、拾った売上金を持ったまま、その場を立ち去ろうとしたところ、Bは、これ以上、抵抗したら何らかの危害を加えられるかもしれないと思い、甲の持ち去りを黙認した。

甲の罪責について、論じなさい。

※ 本問は、大阪地判平4.9.22を素材とする問題である（以下「素材裁判例」という。）。

1 強盗罪（236 I）の成否を検討する。

まず、「暴行又は脅迫」であるが、判例は、「強盗罪の成立には被告人が社会通念上被害者の反抗を抑圧するに足る暴行又は脅迫を加え、それに因って被害者から財物を強取した事実が存すれば足りる」（最判昭23.11.18【百選Ⅱ38】）、「他人に暴行又は脅迫を加えて財物を奪取した場合に、それが恐喝罪となるか強盗罪となるかは、その暴行又は脅迫が、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものであるかどうかと云う客観的基準によって決せられる」（最判昭24.2.8）などとしており、社会通念に沿った客観的基準によるべきであるとする立場に立つと解されている（**論点**「暴行又は脅迫」（236 I）の意義  司 H20,H27,H28）。

 203 頁  87 頁

本問では、刃体の長さ16.5センチメートルの出刃包丁を用いているため、この要件を満たすことは比較的明らかであろう。

2 次に、「強取」の意義であるが（**論点**「強取」（236 I）の意義）、古い判例（前掲最判昭24.2.8）は、「仮りに……被害者に対しては偶々同人の反抗を抑圧する程度に至らなかったとしても恐喝罪となるものではない。」として、強盗既遂罪の成立を認めるものがある。

 204 頁  87 頁

しかし、素材裁判例及び学説の多数は、強盗既遂罪の成立には、暴行・脅迫により、相手方の反抗を抑圧し、その意思によらずに財物を自己又は第三者の占有に移すことが必要とし、強盗未遂罪が成立するに止まるとする。

本問では、甲が出刃包丁を示して「金よこせ。」などと言っている間も、売上金の入ったビニール袋を離さず、引っ張り合いになっている上、ビニール袋が破けて売上金の一部が車外に落ちた際、甲に対して、「拾って来い。」と厳しい口調で命じているBの態度からすれば、Bが反抗を抑圧されたとはいえないであろう。また、Bは、最終的には、抵抗したら何らかの危害を加えられるかもしれないと思い、甲の持ち去りを黙認しており、自己の意思に基づいて、金銭を甲に移転させている。

したがって、上記素材裁判例及び多数説の立場からは、強盗未遂罪が成立するにとどまる。

3 さらに、本問のような場合には、別途恐喝既遂罪の成立を認め、観念的競合になるというのが素材裁判例の処理である。

答案構成

第1 強盗罪の成否について

1 強盗罪（236 I）の成否

↓

2 「暴行又は脅迫」とは、反抗を抑圧するに足りるものでなければならない

↓

あてはめ

↓

3 「強取」とは、相手方の反抗を抑圧し、その意思によらずに財物を自己又は第三者の占有に移すこと（暴行・脅迫、反抗抑圧、財物奪取との間に因果関係があること）を意味する

↓

あてはめ

↓

4 恐怖心が生じて財物が交付されたならば、強盗罪は既遂に達するとする立場（判例）への批判

↓

5 甲には強盗未遂罪（236 I、243）が成立する

第2 恐喝罪の成否について

恐喝罪の実行行為及び故意は強盗罪のそれに包摂される

↓

甲には、恐喝既遂罪（249 I）が成立する

第3 罪数について

強盗未遂罪と恐喝罪が成立し、観念的競合（54 I 前段）となる

第1 強盗罪の成否について

1 甲が刃体の長さ16.5センチメートルの出刃包丁をBの左脇腹付近
に突き付け、「金よこせ。」などと言いながら、左手でビニール袋を
引っ張り、その後、車外に落ちた売上金を拾ってその場を立ち去った行
為について、強盗罪（236条1項）が成立する可能性がある。強盗罪
が成立するには「暴行又は脅迫」が行われる必要があるところ、本件で
かかる要件は満たされるか。

2(1) 「暴行又は脅迫」は、反抗を抑圧するに足りるものでなければなら
ない。

そして、これは構成要件該当性の問題であるから、反抗を抑圧する
に足りるものであるか否かは、一般人を基準とするのが妥当である。

ただし、その判断に当たっては、暴行・脅迫自体の強度・態様に加
え、被害者の性別・年齢、犯行の時刻・場所などの要素を考慮に入
れ、具体的に判断されなければならない。

(2) 本問では、確かに、甲とBは、もともと、A社に勤務していた同僚
であることからすれば、甲の行為も反抗を抑圧するほどの強い暴行で
はないとも思える。

しかし、甲が用いた凶器は、刃体の長さ16.5センチメートルの
出刃包丁であって、高い殺傷能力を有すること、車内という狭い空間
で突きつけられており、逃げ場がないこと、左脇腹付近という人体の
枢要部に向けられていること等に照らせば、甲の行為は、Bの生命又
は身体の安全を害するおそれが高い行為である。加えて、甲とBは、

1

同年代であり、体力に有為な差異があるとはいえない。

以上より、甲の行為は、一般人をして、反抗を抑圧するに足りるも
のであり、「暴行又は脅迫」が認められる。

3(1) 次に、「強取」とは、暴行・脅迫により、相手方の反抗を抑圧し、
その意思によらずに財物を自己又は第三者の占有に移すこと、すなわ
ち暴行・脅迫、反抗抑圧、財物奪取との間に因果関係があることを意
味する。そこで、Bが現に反抗を抑圧されたかを検討する。

(2) 本問では、確かに、Bは、最終的には、これ以上、抵抗したら何ら
かの危害を加えられるかもしれないと思い、甲の持ち去りを黙認して
いる。

しかし、Bは、甲が出刃包丁を示して「金よこせ。」などといっ
ている間も、売上金の入ったビニール袋を離さず、引っ張り合いになっ
ている上、ビニール袋が破けて売上金の一部が車外に落ちた際、甲に
対して、「拾って来い。」と厳しい口調で命じ、甲もこれに従い、即
座に、出刃包丁を上着の内ポケットにしまい、このビニール袋を助手
席において下車し、車外に落ちた売上金を拾っている。

以上の事実からすれば、Bは、甲の行為に屈しているとは解し難
い。また、最終的には、甲の持ち去りを黙認しており、この時点では、
相当程度畏怖している状態であるといえるものの、反抗が抑圧され
たとまではいえず、不本意ながらも甲の持ち去りを黙認して自己の
意思に基づき売上金の一部を交付したにとどまると解するべきであ
る。

2

(3) 以上より、強盗未遂罪が成立するに止まると解すべきである。

4 この点について、恐怖心が生じて財物が交付されたならば、強盗罪は既遂に達するとする立場がある。

しかし、上記のように、強盗罪は被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫を手段とし、財物を奪取する財産罪であるから、暴行・脅迫、被害者の反抗抑圧及び財物奪取のすべてに因果関係が必要である。そうだとすると、相手方が任意に財物を交付する以上、上記因果関係が認められず、強盗罪は、未遂にとどまるというべきである。

5 以上より、甲には強盗未遂罪（236条1項、243条）が成立する。

第2 恐喝罪の成否について

甲の上記行為により、Bは畏怖し、売上金の一部を交付したと評価できる。また、強盗の意思は恐喝の意思を包摂するから、恐喝罪の故意（38条1項）も認められる。

以上より、甲は、「人を恐喝して財物を交付させた」ものとして、恐喝既遂罪（249条1項）が成立する。

第3 罪数について

以上より、甲には、強盗未遂罪と恐喝罪が成立し、「一個の行為が二個以上の罪名に触れ」るため、観念的競合（54条1項前段）となる。

以上